

1500078-21.2021.8.26.0280

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Itariri

Foro: Foro de Itariri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ALESSANDRO LIMA GOMES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA, imputando-lhes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itariri

Foro de Itariri

Vara Única

Rua Engenheiro José Claret de Toledo Goulart, 41, Itariri (SP) - cep 11760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500078-21.2021.8.26.0280 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500078-21.2021.8.26.0280

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ALESSANDRO LIMA GOMES e PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA, imputando-lhes as práticas dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a denúncia que, em 04 de abril de 2021, em horário e local incerto, nesta cidade e comarca, os acusados se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas (Lei n.º 11.343/06) em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Consta também que, no dia 04 de abril de 2021, por volta das 22h19min, nas imediações da Rua Vitorino M. Ribeiro, nº 80, bairro Centro, nesta Cidade e Comarca de Itariri, os réus traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico e sem autorização, 107 gramas de Cocaína, acondicionadas em 91 pinos, 550 gramas de crack, acondicionadas em 375 porções e 141 gramas de maconha, acondicionada em 103 porções, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, auto de constatação preliminar de fls. 14 e laudo de constatação definitiva a ser posteriormente

juntado aos autos, em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Narra que no dia e hora acima descritos, os réus guardavam as drogas mencionadas, destinadas a venda e consumo de terceiros. Ocorre que policiais militares, em patrulhamento de rotina, receberam informações sobre a prática do crime de tráfico de drogas por parte de dois indivíduos que se encontravam no local dos fatos e para lá se dirigiram. Ao ingressarem no local dos fatos, os policiais militares identificaram os réus, que estavam com as mesmas características descritas na comunicação, e decidiram pela abordagem. Nesse momento, os acusados foram questionados a respeito dos fatos e logo confessaram, dizendo que moravam no local há três dias e que estavam comercializando drogas. Logo após, franquearam a entrada dos policiais em suas residências, ocasião em que eles encontraram os entorpecentes referidos supra, junto com uma quantia de R\$ 1.234,00. A diversidade da droga apreendida (Maconha, Crack e Cocaína), e bem como de acordo com as circunstâncias da apreensão, evidenciariam que o acusado trazia consigo as drogas para comercializá-la.

A prisão em flagrante de ALESSANDRO foi convertida em preventiva e a PAULO HENRIQUE foi concedida, inicialmente, a liberdade provisória (fls. 75/80), depois revogada e decretada a preventiva (fls. 159/160).

Notificados, os réus apresentaram defesa (fls. 169/174 e 231/234) e a denúncia foi recebida (fls. 182/183 e 239/240).

Laudo de constatação a fls. 14 e laudo toxicológico definitivo a fls. 292/294.

Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado PAULO HENRIQUE confessa a prática delitiva e ALESSANDRO insiste na negativa de autoria.

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pelo acolhimento da pretensão acusatória, com fixação da pena acima do mínimo legal em razão da quantidade de droga e dos maus antecedentes de ALESSANDRO, agravamento pelo estado de calamidade e afastamento do redutor do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, mas com as atenuantes da confissão e da menoridade de PAULO HENRIQUE. A defesa técnica de PAULO HENRIQUE, pela aplicação do privilégio e fixação da pena no mínimo legal, a ser substituída por restritiva de direitos; e a defesa técnica de ALESSANDRO, pela absolvição do acusado por insuficiência probatória.

A folha de antecedentes atualizada foi acostada a fls. 267/275 e 276/288 e há certidão de distribuição a fls. 287/288 e 289/291.

Fundamentação

Materialidade e Autoria

A materialidade da ação criminosa tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 restou demonstrada pelas provas documental, pericial e oral produzidas.

As declarações dos policiais em juízo confirmam a apreensão de substâncias nos termos do respectivo auto e o perito oficial detectou a presença de tetrahidrocannabinol (THC) e cocaína. De se ressaltar que o perito constatou, apenas, o total de 27,5g de massa líquida de cocaína, 36,1g de massa líquida de crack e 101,4g de massa líquida de maconha.

A própria variedade e quantidade de droga apreendida, bem superior ao que normalmente se destinaria ao consumo próprio de um usuário da droga, corrobora o quanto atestado pelos agentes policiais no sentido de que seu destino não era o consumo pessoal, mas a entrega a terceiros.

Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Para apreciação do vetor objetivo da natureza e quantidade da droga adota-se como parâmetro um consumo diário individual médio de até 2,5g de maconha (cerca de 2 a 4 cigarros), de até 16 pedras de crack (cerca de 5,2g) e de até 0,2g de cocaína, conforme a Portaria 94/1996 dos Ministérios da Justiça e da Saúde de Portugal, sugerida por Maria Tereza Uille Gomes, então Secretária de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Estudo Técnico para Sistematização de Dados

sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, 2014).

Tal quantidade é compatível com o uso semanal médio de 14 cigarros de maconha referido em pesquisa com 80 dependentes da maconha do ambulatório do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da USP (Hercílio Pereira de Oliveira Junior, Avaliação do perfil de comorbidades, gravidade da dependência e motivação para o tratamento em uma amostra de usuários de maconha que procuram tratamento, Mestrado, USP, 2010); e com o uso de até 2g por episódio relatado por 58% de 86 usuários de maconha atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010).

Quanto à cocaína, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o uso de 2g de cocaína por mês um dos vetores para a definição de dependência em pesquisa estadunidense que apurou, ainda, consumo médio mensal de 0,8g de cocaína entre todas as 2.349 pessoas que disseram ter consumido a droga entre 1991 e 1993 (Kevin Chen e Denise Kandel, Relationship between extent of cocaine use and dependence among adolescents and adults in the United States, Drug and Alcohol Dependence, v. 68, 2002), mas é subestimada frente ao uso de até 2g a 5g por episódio relatado por 47% de 87 usuários de cocaína atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010), de modo que aquele valor não deve ser tomado de modo absoluto e deve ser sopesado, por exemplo, com o grau de pureza da droga – ainda assim, no caso, a quantidade é realmente expressiva e desborda do consumo pessoal.

Quanto ao crack, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o padrão médio de uso no Brasil de 13,42 porções por dia apurado por pesquisa da FIOCRUZ, idealizada em conjunto com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Pesquisa Nacional sobre o Uso do Crack, 2014); com o uso de mais de 10 pedras por episódio relatado por 47% de 67 usuários de crack atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010); com o relato de uso de 10 ou mais pedras por 69,5% de 67 usuários de crack atendidos nos Centros de Atenção Psicossocial de Igrejinha, Taquara e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul (Rogério Lessa Horta et al, Perfil dos usuários de crack que buscam atendimento em Centros de Atenção Psicossocial. Cad. Saúde Pública, v. 27, n. 11, p. 2263-2270, 2011); e com a média de 73,2 pedras de crack por semana encontrada em pesquisa com 72 pacientes do Centro de Atenção Psicossocial de Serra, no Espírito Santo (Janine Andrade Moscon, Avaliação dos padrões de consumo de crack, cognição global e de funções executivas em usuários de ambulatório especializado de alta demanda, Mestrado, UFES, 2013).

E a autoria delitiva restou parcialmente comprovada, em relação a PAULO HENRIQUE, pelos elementos probatórios colhidos, somando-se à confissão judicial do acusado (artigo 197 do Código de Processo Penal).

Com efeito, os policiais atestaram ter abordado o acusado em via pública, em local no qual observaram características próprias à comercialização da droga, com ele encontrando entorpecentes e, depois, verificaram ter mantido em depósito em uma casa a maior parte das drogas apreendidas.

Eder disse que havia recebido denúncia de indivíduos de outras cidades na prática do tráfico de drogas, tanto na praça quanto na Rua Vitorino M. Ribeiro. Efetuaram patrulhamento no local e se depararam, próximo à residência da denúncia anônima, com uma movimentação suspeita. Cerca de 4 indivíduos correram – entre eles um conhecido usuário –, mas PAULO HENRIQUE e ALESSANDRO foram abordados e revistados, encontrados com PAULO HENRIQUE droga (2 pinos) e com ALESSANDRO dinheiro em espécie (150 a 200 reais). Indagados, entraram em contradição, mas PAULO HENRIQUE acabou confessando o tráfico e que havia mais droga dentro da casa. Obtido apoio de outra viatura, adentraram a residência e encontraram em uma caixa um pacote contendo mais

drogas. Diante disso, ALESSANDRO acabou confessando também a participação, cabendo a ele receber e guardar o dinheiro. Trabalha há mais de 8 anos na cidade, em que nasceu e cresceu, mas nunca tinha visto os acusados. Falaram que estavam na casa há três dias, alugada para o comércio da droga. Já estavam morando na casa. Não se recorda se PAULO HENRIQUE referiu o consumo de droga. Na denúncia, recebeu informação sobre a vestimenta (cor da bermuda, camiseta) e, por não os conhecer, acreditou que eles eram os traficantes. Sabe que os outros que correram não tinham vestimenta com as mesmas características da denúncia.

Eduardo Pires, policial, disse que estava em patrulhamento e foi irradiado via COPOM denúncia de dois indivíduos praticando tráfico de drogas em via pública, com informação sobre suas vestimentas. Deslocaram-se para o local da denúncia e avistaram de 3 a 5 indivíduos que correram com a aproximação da viatura. Dentre eles, identificaram 2 com roupas semelhantes à denúncia e os revistaram. PAULO HENRIQUE portava 2 eppendorf e ALESSANDRO, dinheiro em espécie. Indagado, PAULO HENRIQUE confessou que estava há 3 dias na cidade e na residência, na prática do tráfico, e que no interior da residência havia mais drogas e dinheiro. Com a vinda da outra viatura policial e franqueado o acesso à residência, encontraram mais droga e dinheiro (numa bolsa preta, que seria de ALESSANDRO). Não conhecia os acusados, até porque trabalha ordinariamente em Peruíbe. Nada sabe quanto à organização da empreitada criminoso senão que PAULO HENRIQUE guardaria a droga e ALESSANDRO, o dinheiro. Ninguém mais estava na residência. Não se recorda se alguém mencionou ser usuário, mas PAULO HENRIQUE não aparentava estar sob efeito. Não sabe há quanto tempo estavam na venda, tendo chegado em menos de 5 minutos após a abertura da denúncia. Os indivíduos estavam nervosos, como de costume em abordagens da espécie, mas não tentaram se evadir. Não se recorda da descrição passada, mas apenas que ela batia com a dos acusados. Havia vários indivíduos no local, mas as características batiam com ALESSANDRO e PAULO HENRIQUE, que foram os abordados. Não se recorda a que título estavam naquela residência, supostamente há 3 dias. Contudo, não restou comprovada a participação de ALESSANDRO.

Negados os fatos pelo acusado, o único elemento probatório no sentido da versão acusatória que veio aos autos foi o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Não há qualquer outra prova que possa ser confrontada com o depoimento e a ele se somar. Nada mais há a ligar o acusado à conduta criminoso. Ao que se entende, a presunção de legalidade do ato administrativo não se aplica à esfera penal, norteadas pela estrita presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), devendo a pretensão acusatória ser comprovada em juízo por elementos intersubjetivos.

Não se está a duvidar da veracidade dos depoimentos prestados a este juízo por quem cumpre nobre e corajosa função no sistema de segurança pública em uma sociedade brasileira tão desigual e fragmentada, mas o Estado de Direito exige algo mais para legitimar a privação de direitos.

Mutatis mutandis é o que levou o Superior Tribunal de Justiça a exigir mais do que a palavra dos agentes policiais para resultar válida a autorização de ingresso no domicílio, verbis: "7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça. 7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu no caso ora em julgamento - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da

documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado." (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Tal entendimento também foi sufragado pela Quinta Turma: HC 616.584/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021.

Crer que a palavra dos policiais envolvidos na formação da opinião delicti seja suficiente para a condenação desde que não infirmados ou refutados pela defesa é impor indevida inversão do ônus probatório, que é da acusação, e violar, por via transversa, o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal (cf. Aury Lopes Jr., Direito Processual Penal, 18ª ed., Saraiva, 2021, p. 529-530). Afinal, em última análise, o destino do acusado já estaria selado tão somente pela atuação do agente policial.

No caso, a situação se agrava diante do quanto atestado pelas testemunhas, que disseram não conhecer ALESSANDRO, que estaria de bermuda e chinelo - daí terem concluído se tratar, a partir da denúncia anônima, que era ele, também, o traficante do ponto de venda da droga. Com ele, porém, nada de ilícito foi com ele encontrado. Note-se que os agentes policiais sequer realizaram campana, por exemplo, para se assegurar de quem estaria vendendo a droga. A confissão informal e o acesso à residência teriam sido dados por PAULO HENRIQUE, somente - e que, em juízo, negou a participação de ALESSANDRO, que seria apenas usuário.

Em tal contexto, não se pode descartar a versão corroborada pela informante Samantha Boina de Oliveira, mulher de ALESSANDRO, de que ele seria apenas usuário que foi ao local comprar drogas. Disse que foram para Itariri com amigos, para viagem de lazer, e, no dia dos fatos ele saiu de manhã e voltou à tarde com bafo alcoólico. Ficou brava com ele, inclusive diante do histórico de dependência de drogas. ALESSANDRO saiu de novo, sem dizer aonde ia, e não voltou. Foi embora e ficou sabendo depois, via celular e por policial, que ALESSANDRO havia sido preso, sem maiores detalhes. Trabalhava como gesseiro e tinha dinheiro. ALESSANDRO já foi preso outras vezes, mas não sabe o motivo. Conhece ALESSANDRO há 3 ou 4 anos e ele já era dependente, segundo sabe cocaína, mas nunca na sua frente. Sempre trabalhou. Quanto à imputação da conduta prevista no artigo 35 da lei 11.343/06, não há nos autos elementos probatórios que demonstrem, seguramente, o prévio conluio habitual para a prática da traficância.

Primeiro que, como se disse, não há prova da participação de ALESSANDRO, único indivíduo apontado na denúncia como associado a PAULO HENRIQUE, o que por si só já afastaria a caracterização do delito.

Mas há mais. A associação para o tráfico, para restar configurada, depende de demonstração da convergência da vontade dos agentes, no sentido de se unirem de modo estável e permanente, com o objetivo específico de violar o disposto nos artigos 33 e 34 da Lei 11.343/06. Exige-se mais do que elementos que evidenciem o grau de organização dos agentes, sendo indispensável a prova de estabilidade e permanência da associação criminosa, da prática delitiva habitual, tratando-se, portanto, não uma ação criminal episódica e oportunista que caracteriza o mero concurso de agentes.

No caso, não há referência a prévia investigação e não há qualquer fato, anterior ou posterior ao contexto fático do flagrante, que indique a reiteração do episódio. Enfim, o titular da ação penal não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, restando dúvida quanto à responsabilidade penal do acusado ALESSANDRO, por todos os crimes, e de PAULO HENRIQUE, pelo crime do artigo 35. Assim, não afastada a presunção de inocência a todos assegurada pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, corolário de um Estado Democrático de Direito, impõe-se a absolvição.

Adequação Típica

Prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

Porém, a acusação não logrou demonstrar que o agente seja reincidente, tenha maus antecedentes, se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, razão pela qual aplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Ao contrário, o único elemento nesse sentido foi a folha de antecedentes, que indica a primariedade de PAULO HENRIQUE.

Note-se que a apreensão de quantidade não módica de droga em poder do acusado não é indício suficiente para, isoladamente, permitir se conclua que o acusado se dedica às atividades criminosas, pois daí não se extrai conclusão segura (STF, HC 138138, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016), a menos que se trate de quantidade realmente exorbitante ou que haja outros indícios, o que não é o caso.

Quanto à agravante invocada pelo Ministério Público, do artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, embora praticado o crime em 1º de fevereiro de 2021, na vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Estadual 64.879/20 e do Decreto Estadual 65.437/20, estabelecendo medidas de quarenta, tudo consoante a Lei Federal 13.979/20, então também vigente nos termos da Medida Cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6625, não há comprovação de qualquer relação entre o fato criminoso e a pandemia do COVID-19.

Conforme já se decidiu, “não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o réu tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (Apelação 1519970-09.2020.8.26.0228, Rel. Camargo Aranha Filho, 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 05/04/2021). No mesmo sentido, exigindo relação entre o estado de calamidade pública e o delito: Apelação 1513037-20.2020.8.26.0228, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13ª Câmara de Direito Criminal; Apelação 1510408-25.2020.8.26.0050, Rel. Ricardo Sale Júnior, 15ª Câmara de Direito Criminal; j. 08/04/2021; Apelação 1507142-78.2020.8.26.0228, Rel. Tetsuzo Namba, 11ª Câmara de Direito Criminal; j. 07/04/2021; Apelação 1523117-43.2020.8.26.0228, Rel. Klaus Marouelli Arroyo, 7ª Câmara de Direito Criminal; j. 06/04/2021; Apelação 1507313-35.2020.8.26.0228, Rel. Diniz Fernando, 1ª Câmara de Direito Criminal; j. 06/04/2021.

Ilícitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que excluiria a ilicitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal.

À época dos fatos, o réu era maior de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de não tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, o réu tinha ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, no procedimento trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal, na medida em que necessária e suficiente à retribuição e à prevenção especial.

Na primeira etapa (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), aprecio as

circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis a partir da pena média, a fim de atender o princípio da isonomia do artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pois “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. Esse é um ponto estratégico na individualização da pena, justamente para evitar a nociva padronização. A quem merece pena superior ao mínimo, deve o juiz saber aplicá-la, por uma questão de justiça.” (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Penal, v. 1, 3ª ed., 2019, Cap. XXXII, item 3.1, p. 1020). Do contrário, dar-se-ia idêntico tratamento para condutas de distinta reprovabilidade quando presentes exclusivamente circunstâncias judiciais favoráveis.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. O acusado não ostenta maus antecedentes, inexistindo condenação criminal transitada em julgado a ser valorada nesta fase, conforme exige a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social do acusado, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade do acusado, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, *Fermín Ramírez vs. Guatemala*, julgado em 20/06/2005).

Os motivos e as circunstâncias do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

A natureza e a quantidade da droga são pequenas, conforme atestado pelo laudo pericial, e autorizam um juízo favorável ao acusado, pois inferiores ao suprimento mensal de um usuário de droga, nos termos já adotados.

Por tudo isto, considerado favoráveis a conduta social e a natureza e quantidade da droga e neutras as demais circunstâncias. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, atribuo peso equivalente a 1/5 para as circunstâncias relativas à natureza e a quantidade da droga, à personalidade e à conduta social do agente e 1/6 para as demais, tudo sobre o intervalo de pena em abstrato a cada circunstância favorável e desfavorável. A fração é eleita em interpretação sistemática da fração mínima das causas de aumento e diminuição expressas no Código Penal, aplicando-se sobre o intervalo em respeito ao papel do legislador na individualização da pena, de modo que possa alcançar, em tese, o piso ou o teto legais.

Fixo a pena-base em 6 anos de reclusão.

Na segunda etapa (artigos 61 a 67 do Código Penal), é de rigor a atenuação da pena em razão da confissão (artigo 65, inciso III, 'd', do Código Penal) e em razão da menoridade (artigo 65, inciso I, do Código Penal).

Por conseguinte, atenuo a pena em 1/3 sobre o intervalo de pena em abstrato, que é reduzida para o mínimo de 5 anos.

Por fim, na terceira etapa, reduzo a pena de 2/3, no patamar máximo do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, do qual não se extrai critério seguro para gradação, em ofensa ao princípio da legalidade (artigo 5º, incisos II e XXXIX, da

Constituição Federal), evitando-se, ainda, inadmissível bis in idem na dupla valoração das circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal combinado com o artigo 42 da Lei 11.343/06) na primeira e na terceira etapas. Assim, fixo a pena privativa de liberdade em 1 anos e 8 meses de reclusão. Quanto à pena pecuniária, a gradação do número de dias-multa deve observar rigorosamente o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, conforme tudo o que já se expôs.

Assim, correspondendo a pena-base a 600 dias-multa e a pena intermediária a 500 dias-multa, fixo a pena de multa final em 166 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa, nos moldes do art. 43 da Lei 11.343/06, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Regime inicial

Deixo de promover a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Diante da condenação a pena igual ou inferior a 4 anos, da primariedade do réu e das circunstâncias judiciais que não se mostram desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'c', do Código Penal (Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal).

É inaplicável ao tráfico privilegiado a previsão constante do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, porque não se trata de crime equiparado a hediondo, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016), ao que se curvou o Superior Tribunal de Justiça revendo a tese fixada em recurso repetitivo e cancelando a sua Súmula 512, para assentar que “o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo” (Pet 11.796/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016).

Substituição e sursis

Diante das circunstâncias judiciais em torno do crime e do acusado (artigos 44, inciso III, e 59, inciso IV, do Código Penal) e do preenchimento dos requisitos objetivos dos incisos I e II do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade superior a 1 ano por duas restritivas de direitos, na forma do artigo 44, parágrafo 2º, do Código Penal, lembrando que o Senado Federal suspendeu a execução, nesta parte, da vedação disposta no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 após decisão do Supremo Tribunal Federal.

A fim de atender às finalidades preventiva e retributiva da sanção penal e permitir, na medida do possível, a restauração dos efeitos do delito na comunidade, determino a substituição por prestação de serviços à comunidade ou a entidades pública (artigo 46 do Código Penal), a ser especificada e adaptada quando da execução (artigos 148 e 149 da Lei de Execução Penal), e pela interdição temporária de direitos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, ficando o acusado proibido de frequentar as imediações do local do fato, em que mantido ponto de comércio de entorpecentes, pelo tempo da pena privativa de liberdade.

Indicada a substituição da pena por restritiva de direitos (art. 44 do CP), é incabível a suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP), até porque aquela se mostra mais propícia à rápida ressocialização do acusado.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para condenar PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA à pena de reclusão de 1 anos e 8 meses, em regime inicial aberto, e a 166 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com a causa de diminuição do parágrafo 4º do mesmo dispositivo, substituída pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e de proibição de frequentar as

imediações do local do fato; ABSOLVO-O da imputação da prática do crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ainda, julgo improcedente a pretensão acusatória e ABSOLVO o acusado ALESSANDRO LIMA GOMES da imputação da prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, e da imputação da prática do crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Prisão preventiva

Nos termos do artigo 387, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, aprecio e revogo a prisão preventiva de ambos os acusados, a de PAULO HENRIQUE, porque incompatível com o regime inicial de cumprimento de pena ora fixado. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade.” (HC 193996 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020). No mesmo sentido: HC 136397, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016.

Considerando a necessidade de garantir a ordem pública e, sobretudo, de assegurar a aplicação da lei penal, é necessário, adequado e suficiente a concessão da liberdade provisória mediante a determinação de a) comparecimento perante a autoridade policial ou judicial todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento; b) proibição de se ausentar da Comarca por mais de 8 dias sem prévia autorização do Juízo; c) não mudar de endereço sem prévia autorização do juízo, tudo na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assim, expeça-se, com urgência, o alvará de soltura clausulado.

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno PAULO HENRIQUE ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Com o trânsito em julgado, determino a destruição das amostras da droga guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06. Comunique-se à autoridade policial.

Com o trânsito em julgado, expeça-se a guia de recolhimento definitiva, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ 113/2010; comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; e comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal).

Int.

Itariri, 08 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA